

1500248-98.2021.8.26.0633

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas

Magistrado: JOÃO COSTA RIBEIRO NETO

Comarca: Peruíbe

Foro: Foro de Peruíbe

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 07/04/2022

... do menor R. S. do C. para a prática do tráfico. Era o adolescente quem realizada o tráfico de drogas propriamente dito, sob a coordenação do réu. O acusado expôs a infância e a personalidade do menor, enquanto bem jurídico, à grave lesão. A exposição ao tráfico de drogas, a exemplo do crime de corrupção de menores, é formal (Inteligência da Súmula 500, STJ). E, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Peruíbe

Foro de Peruíbe

1ª Vara

Rua Nilo Soares Ferreira, nº 185, Peruíbe-SP - cep 11750-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500248-98.2021.8.26.0633 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500248-98.2021.8.26.0633

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2227926/2021 -

DEL.POL.PERUIBE, 2509/2021 - DEL.POL.PERUIBE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WANDERLEI BATISTA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOÃO COSTA RIBEIRO NETO

RELATÓRIO

WANDERLEI BATISTA foi denunciado como incurso no crime do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, c/c o artigo 61, II, alínea "j", na forma do artigo 29, ambos do Código Penal, porque, conforme constou, no dia 21 de agosto de 2021, por volta das 11h00, na rua Olimpia, nº 531, Casablanca, nesta cidade e Comarca de Peruíbe/SP, o adolescente Rodrigo Silva do Carmo, em unidade de desígnios e contando com a participação do maior imputável WANDERLEI BATISTA, teria trazido consigo, para fins de tráfico e sem autorização, 86 porções de cocaína, com peso bruto de 120,44 gramas, além da quantia em dinheiro de R\$ 270,00, praticando o ato infracional em ocasião de calamidade pública decretada em razão da Pandemia da COVID-19. Constou, ainda, que nas mesmas condições de tempo e

local, WANDERLEI BATISTA, teria concorrido para prática delitativa acima descrita, na medida em que exercia a função conhecida como "campana", a fim de garantir o sucesso da empreitada delitativa, praticando o crime em ocasião de calamidade pública decretada em razão da Pandemia da COVID-19.

Recebida a denúncia (fls. 81/83), o réu foi citado (fl. 117) e ofertou resposta à acusação (fls. 121/123).

Confirmado o recebimento da denúncia (fl. 124), foi designada audiência de instrução e julgamento (fls. 139/140), na qual foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, tendo sido, ao final, interrogado o acusado.

Encerrada a instrução, em alegações finais orais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia, ao passo que a defesa postulou a absolvição do réu e, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

A materialidade delitativa restou demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 10/13), pelo auto de exibição/apreensão/entrega (fl. 14), pelo laudo pericial (fls. 93/95), bem como pela prova oral colhida.

A autoria, de igual modo, é plena e cabal, a começar pelo estado flagrancial (fl. 5), secundado pelo robusto conjunto probatório produzido nos autos.

As testemunhas policiais, nas fases policial e judicial, confirmaram a versão da acusação. Os policiais disseram que, na data dos fatos, estavam em patrulhamento pelo Bairro Caraguava, quando avistaram um indivíduo que, ao visualizar a viatura, começou a gritar a palavra "água", alertando outro indivíduo sobre a presença da viatura. Informaram que, nesse momento, a equipe aumentou a velocidade e logrou êxito em abordar o "campana", que permaneceu detido. Disseram que passaram a acompanhar o outro indivíduo, por alguns metros, também logrando êxito em abordá-lo, mais a frente, na mesma via.

Relataram que, em revista pessoal efetuada, foram localizadas no bolso da jaqueta desse indivíduo 86 porções de cocaína, bem como a quantia de R\$ 270,00 em cédulas trocadas. Declararam que tal indivíduo não portava documento de identificação, ocasião na qual, questionado, disse tratar-se de menor de idade e que, portanto, "ainda não teve tempo de tirar o RG", identificando-se a seguir como R. S. do C.. Explicaram que o outro indivíduo, o "campana", era WANDERLEI BATISTA, ora acusado nos autos. Disseram que, em consulta junto ao Sistema COPOM, Wanderlei constou como procurado da justiça, com pena a cumprir pelo artigo 155 do CP. Relataram que, diante dos fatos, foi dada voz de prisão a ambos, sendo conduzidos à UPA de Peruíbe e, após, ao Plantão Policial.

O réu negou o delito, apresentando uma versão bastante inverossímil e dissociada do conjunto probatório.

Os elementos de informação do inquérito restaram integralmente confirmados em audiência. Ficou claro que, no dia dos fatos, o adolescente R. S. do C. realizava o tráfico de drogas com o auxílio direto do acusado, que exercia a função de "campana". Os policiais afirmaram de forma harmônica e segura esse fato. Nenhuma pergunta feita conseguiu colocar em xeque os depoimentos prestados.

Há, portanto, prova concreta e segura da materialidade e da autoria do acusado quanto ao crime do art. 33, caput, da LD, na forma do art. 29 do CP.

No mais, deve ser aplicada a causa especial de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da LD, já que o delito foi praticado em concurso com menor de idade, conforme seguramente relatado pelas testemunhas policiais.

A condenação é de rigor.

Passo à fixação das penas.

Na primeira fase, considerando os critérios do artigo 42 da Lei de Drogas e as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, verifico que o tipo da droga é bastante nocivo. Trata-se de apreensão de 86 porções de cocaína. Cocaína é droga com altíssimo poder de dependência química. Sua nocividade é especialmente alta e deve ser considerada na reprimenda do crime.

Por fim, observo que o aumento pelas circunstâncias não deve limitar-se a 1/6 neste caso concreto. Além de não existir parâmetro algorítmico previsto em lei, no caso

concreto, à luz das finalidades da pena, o aumento deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta e com a preponderância de cada circunstância judicial, fundamentadas acima. É o que tem reiteradamente decidido o STJ (AREsp 1.413.531/GO; HC 495.389/PE; HC 462.924/SP) e o STF (AP 470/DF), prevalecendo, sobretudo para o STJ, que o aumento acima de 1/6 é plenamente justificado, desde que "haja fundamentação concreta".

O STF decidiu, inclusive, que o aumento pode e deve ser até bem superior do que 1/6 em importante julgamento realizado pelo Pleno daquela Corte (RvC 5475, Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, j. 6/11/19). É o que deve ocorrer no presente caso, conforme fundamentado acima.

Registro, ainda, que o aumento de pena, mesmo na primeira fase, deve ser calculado com base no intervalo entre a pena máxima e a pena mínima, a fim de respeitar a vontade do legislador, ao fixar os respectivos intervalos de pena, à luz da política criminal que entender mais adequada.

Para cada aumento, deve ser aplicado valor entre as frações de 1/8 a 1/6 sobre o intervalo entre a pena máxima e a mínima. No caso concreto, entendo, à luz da gravidade em concreto e da preponderância de cada aumento, que devem ser acrescidos 8 meses para a circunstância negativa.

Assim, fixo a pena-base em 5 anos e 8 meses de reclusão e 566 dias-multa.

Na segunda fase, não incide a atenuante da confissão. O réu não confessou o delito (Súmula 545, STJ, a contrario sensu).

Incide a agravante da calamidade pública.

A agravante da calamidade pública é de ordem subjetiva. Sua incidência pressupõe o efetivo aproveitamento do contexto de pandemia para a prática do delito, não bastando apenas que o delito tenha sido praticado durante a vigência dos Decretos que reconheceram o estado de calamidade pública em razão da pandemia da COVID-19. É o que tem reiteradamente decidido o STJ (HC 632.019/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 10/2/2021; HC 629.981/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 9/2/2021; HC 620.531/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 3/2/2021; e HC 625.645/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 04/12/2020).

No caso concreto, há elementos que evidenciam que o réu se prevaleceu, efetivamente, da situação e do contexto da pandemia para a prática do delito. O réu praticou o delito acreditando que sairia impune, pela dificuldade de se identificar o crime, em razão da diminuição do fluxo de pessoas nas ruas ocasionada pela pandemia. Não esperava que seria abordado pela polícia. Claramente, achou que ficaria impune. O réu valeu-se, portanto, da calamidade que, no caso concreto, efetivamente dificultou a repressão ao crime. Incide, portanto, a agravante do art. 61, II, "j", do CP.

Fixo a pena intermediária em 6 anos e 4 meses de reclusão e 632 dias-multa.

Na terceira fase, incide a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas. O réu utilizou-se do menor R. S. do C. para a prática do tráfico. Era o adolescente quem realizava o tráfico de drogas propriamente dito, sob a coordenação do réu. O acusado expôs a infância e a personalidade do menor, enquanto bem jurídico, à grave lesão. A exposição ao tráfico de drogas, a exemplo do crime de corrupção de menores, é formal (Inteligência da Súmula 500, STJ). E, ainda, no caso concreto, os efeitos sobre a vida do menor são especialmente lesivos à sua formação. A corrupção do menor dificilmente será desfeita. Os impactos das escolhas do réu são duradouros. E projetam-se sobre a vida do menor infrator. O aumento deve incidir no patamar de 1/6, portanto.

Incide, ainda, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, mas a diminuição deve incidir no patamar mínimo de 1/6. A atividade demonstrou ampla profissionalização. O crime foi praticado em concurso de agentes. O réu valia-se do menor R. S. do C. para a prática do tráfico propriamente dito, sempre sob a sua coordenação. O acusado desempenhava o papel de "campana". Ao chegar a polícia, o réu começou a gritar a palavra "água", para alertar ao menor sobre a presença dos policiais. A atividade era desenvolvida de forma bastante e organizada, portanto. E o réu era quem coordenava toda a atividade criminosa naquele local. O contexto da prisão, o modus operandi da atividade criminosa, exercida em concurso de pessoas – sendo o outro agente pessoa menor de idade – e de forma especialmente organizada, e

a forma como as drogas estavam minuciosamente embaladas (86 porções de cocaína) denotam o grau de profissionalização e de envolvimento do acusado com a narcotraficância. Esses fatores devem ser sopesados à luz das finalidades preventiva e repressiva da pena.

E mais: a despeito de sua primariedade, o réu responde pelo delito de furto qualificado (processo nº 1501996-73.2018.8.26.0536, cf. fls. 157/158), cujo processo estava suspenso pelo art. 366 do CPP antes da prisão nesses autos. O réu também possui passagens criminais por outros fatos criminosos. Agora, passa a ser concretamente condenado pelo delito de tráfico, o que evidencia certa dedicação, ainda que não propriamente habitual, ao crime.

Noutras palavras: o réu deve ser contemplado com a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º da Lei de Drogas no patamar mínimo, porque seu comprometimento com o mundo do crime é bastante intenso, chegando muito próximo do habitual. O réu merece uma resposta estatal mais severa, pelo que se verificou em audiência.

O aumento e a diminuição são no patamar de 1/6. Mas não há compensação. Primeiro deve incidir o aumento e depois a diminuição, porque é mais benéfico ao acusado. Fixo a pena definitiva em 6 anos, 1 mês e 26 dias de reclusão e 614 dias-multa.

À luz das circunstâncias judiciais especialmente negativas, concretamente fundamentadas, e do comportamento particularmente nocivo do réu, que se valeu de menor de idade para realizar a traficância propriamente dita, fixo como inicial o regime fechado (art. 33, § 3º, CP, c/c art. 59, CP).

Restam inaplicáveis os arts. 44 e 77 do CP, por ausência dos pressupostos objetivos e subjetivos.

DISPOSITIVO

Em razão do exposto, no mérito, julgo procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu WANDERLEI BATISTA, como incurso no crime do art. 33, caput, da LD, c/c art. 40, VI, da LD, às penas de 6 anos, 1 mês e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 614 dias-multa, no mínimo legal cada.

O réu deverá permanecer preso.

Concretamente, trata-se de crime bastante grave. O tráfico de drogas foi praticado em concurso de agentes. O acusado valeu-se de menor de idade, para a prática do crime. Era o menor quem realizava a traficância propriamente dita, sempre sob a coordenação e a orientação do acusado, que atuava como "campana". O contexto da prisão, o modus operandi da atividade criminosa, exercida em concurso de pessoas – sendo o outro agente pessoa menor de idade – e de forma especialmente organizada, e a forma como as drogas estavam minuciosamente embaladas (86 porções de cocaína) denotam o grau de profissionalização e de envolvimento do acusado com a narcotraficância.

E mais: a despeito de sua primariedade, o réu responde pelo delito de furto qualificado (processo nº 1501996-73.2018.8.26.0536, cf. fls. 157/158), cujo processo estava suspenso pelo art. 366 do CPP antes da prisão nesses autos. O réu também possui passagens criminais por outros fatos criminosos. Não se trata, portanto, do primeiro contato do acusado com o meio criminoso. Ao contrário, todas essas circunstâncias revelam que o seu comprometimento com o mundo do crime é bastante intenso, chegando muito próximo do habitual.

O fumus commissi delicti está agora sobejamente demonstrado, em juízo de cognição plena e exauriente. O periculum libertatis decorre da gravidade concreta do delito, do comportamento e histórico bastante nocivos do réu e da alta probabilidade de reiteração delitiva. A manutenção da segregação cautelar do réu é a medida que se impõe.

Em razão do exposto, mantenho a prisão do acusado, para a garantia da ordem pública.

Recomende-se o réu onde encontra-se preso.

PROVIDÊNCIAS FINAIS

Após o trânsito em julgado: (a) oficie-se à Justiça Eleitoral (art. 15, III, CF); (b) intime-se o réu a pagar a multa em 10 dias (art. 50 do CP e art. 686 do CPP); e

(c) lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Oportunamente, extraia-se a Guia de Cumprimento de Pena (arts. 105 e 106 da LEP e Res. 113/2010 do CNJ).

Decreto, em favor da União, o perdimento dos bens eventualmente apreendidos, arrestados ou sequestrados nestes autos (art. 91, II, CP).

Autorizo a incineração da droga, conforme previsto em lei.

Deixo de aplicar o art. 387, § 2º, do CPP, por não alterar o regime inicial de cumprimento de pena e por não ser possível aferir nesse momento processual os requisitos subjetivos para a progressão.

Deixo de fixar mínimo indenizatório (art. 387, IV, CPP), por ausência de pedido expresso, o qual configura requisito indispensável para tanto, consoante a posição do STJ.

Condeno o réu ao pagamento de custas na forma da lei (art. 804, CPP), observada a concessão de gratuidade processual, se o caso.

Tomem-se as providências do art. 809 do CPP.

Sentença publicada em audiência.

JOÃO COSTA NETO

Juiz de Direito

Peruíbe, 5 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA